

不作為犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 詐欺罪については積極的な欺罔行為を要するから、不作為による欺罔行為が認められることはない。
2. 不作為による幫助犯が成立するためには、作為に出ることで確実に正犯の実行を阻止できたという関係は不要である。
3. 結果犯における不真正不作為犯の故意について、結果の発生を積極的に意欲することは不要である。
4. 不作為による殺人罪が成立するためには、行為者と生命の危機に瀕した者との間に親族関係や契約関係が必要であるから、行為者が、そのような関係にない重篤な患者に対する医師の治療を打ち切らせて同患者を一人暮らしの自宅に引き取った上、その生命を維持するために必要な医療措置を受けさせずに同患者を死亡させたとしても、殺人罪は成立し得ない。
5. 不真正不作為犯の成立には、作為可能性を必要としない場合がある。

No.25	不作為犯	正答率
R5-9	正解 2、3 (順不同)	96%

1 誤っている

欺罔行為とは、取引の相手方が真実を知っていれば財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいうが、欺罔行為は不作為によっても可能である。既に相手方が錯誤に陥っていることを知りながら真実を告知しない場合には、不作為による欺罔行為が認められ得る。もっとも、不作為による欺罔行為が認められるためには、告知義務の存在が必要とされている。判例は、生命保険契約の締結に際して既往症を告知しなかった場合に法令上の告知義務違反があったとして（大判昭7.2.19）、また、誤振込みであることを秘して預金の払戻しを受けた場合に信義則上の告知義務違反があったとして（最決平15.3.12、百選Ⅱ52事件）、不作為による欺罔行為を認めている。よって、詐欺罪の成立には積極的な欺罔行為を要するわけではなく、不作為による欺罔行為も認められ得る。したがって、本記述は誤っている。

2 正しい

札幌高判平12.3.16（百選Ⅰ85事件）は、被告人の子が被告人の内縁の夫から暴行を受けており、被告人は、それを認識していたにもかかわらず、何ら制止する行為をしなかったところ、その子が死亡したという事案において、「原判決が掲げる『犯罪の実行をほぼ確実に阻止し得たにもかかわらず、これを放置した』という要件は、不作為による幫助犯の成立には不必要というべきである」とした上で、「不作為による幫助犯は、正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が、一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに、そのことを認識しながら、右一定の作為をせず、これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした場合に成立し、以上が作為による幫助犯の場合と同視できることが必要と解される」としている。裁判例の結論に賛成する学説は、その理由として、幫助行為は正犯結果を促進し容易にしたことで足りるという幫助の因果関係の理解を前提とすれば、不作為による幫助についても、作為に出ることによって結果発生を困難にした可能性があるという関係で足りるということを挙げている。

なお、本判例においては、被告人に要求される作為としては、内縁の夫が子に暴行を加えないように監視する行為、あるいは、暴行を言葉で制止する行為を想定できるが、被告人の不作為の結果、これらの作為がなされた場合に比べ、内縁の夫の子に対する暴行が容易になったことは疑いがなく、被告人に不作為による傷害致死幫助罪（205条、62条1項）の成立を認めた。

3 正しい

最判昭33.9.9（百選Ⅰ5事件）は、被告人が、室内で火鉢を使用していたところ、そこから机等に引火したため、火の不始末の発覚を恐れてそのまま同所から立ち去り、結果として建物を全焼させたという事案において、被告人の消火義務を認めた上で、「被告人は自己の過失により右原付、木机等の物件が焼燬されつつあるのを現場において目撃しながら、その既発の火力により右建物が焼燬せられるべきことを認容する意思をもつてあえて被告人の義務である必要かつ容易な消火措置をとらない不作為により建物についての放火行為をなし、よつてこれを焼燬したものであるということが出来る」と故意も認め、不作為による現住建造物等放火罪の成立を認めた。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、不真正不作為犯の構成要件は作為犯と同じく客観的要素と主観的要素から成るところ、不真正不作為犯の成立範囲を限定する役割は、不真正不作為犯に特有の客観的構成要件要素（作為義務など）と行為の客観的帰属（作為と不作為の等価値性）が果たすため、主観的構成要件要素としては、作為犯と同様に、未必の故意があれば足りるということを挙げている。よって、結果犯における不真正不作為犯の故意については、結果の発生を積極的に意欲することまで必要ではない。

4 誤っている

最決平 17.7.4 (百選 I 6 事件) は、独自の治療法を有すると称していた被告人が、脳内出血で入院中の信奉者の治療を依頼されたため、同人を病院から自身が滞在中のホテルに運ばせ、その後は独自の治療法を施すにとどまり、必要な医療措置を受けさせないまま放置したことにより、同人を死亡させたという事案において、「被告人は、自己の責めに帰すべき事由により患者の生命に具体的な危険を生じさせた上、患者が運び込まれたホテルにおいて、被告人を信奉する患者の親族から、重篤な患者に対する手当てを全面的にゆだねられた立場にあったものと認められる。その際、被告人は、患者の重篤な状態を認識し、これを自らが救命できるとする根拠はなかったのであるから、直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていたものというべきである」と作為義務を肯定した上で、不作為による殺人罪の成立を認めている。作為義務の根拠としては、親族関係や契約関係など、救助することが強く期待される特別な関係(保護関係)が存在する場合もあるが、その他にも、本判例のように、危険を創出する先行行為がなされた場合(「自己の責めに帰すべき事由により患者の生命に具体的な危険を生じさせた」こと)や依存関係・保護の引受けがある場合(「患者が運び込まれたホテルにおいて、被告人を信奉する患者の親族から、重篤な患者に対する手当てを全面的にゆだねられた立場にあった」こと)などもある。よって、不作為による殺人罪が成立するためには、必ずしも行為者と生命の危機に瀕した者との間に親族関係や契約関係が必要となるものではなく、本記述のような場合であっても、不作為による殺人罪が成立し得る。したがって、本記述は誤っている。

5 誤っている

不真正不作為犯の成立要件としては、一般的に、作為義務の存在及び作為可能性・容易性が挙げられており、作為義務の存在が認められたとしても、作為可能性がない場合には、不真正不作為犯の成立は否定される。これは、例えば、子どもが海で溺れているところ、救助すべき義務を負う親も泳げないような場合、その親に対して、自身の生命・身体の危険を負わせてまで救助を強いることを正当化できないように、行為者に無理を強いることはできないためである。よって、不真正不作為犯の成立には、作為可能性が必要不可欠である。したがって、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述は2と3であり、したがって、正解は肢2と肢3(順不同)となる。